

0004037-12.2017.8.26.0637

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: JOSE AUGUSTO FRANCA JUNIOR

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Anexo do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... e aparelhar todo o sistema de consumo e tráfico de drogas existente na sociedade.

No mesmo sentir, "a punição, na hipótese, é de rigor para salva guardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Anexo do Juizado Especial Criminal

Rua Colômbia, 200, Jardim América, Tupã - SP - cep 17605-900

#### TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital:

0004037-12.2017.8.26.0637

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DE MELO PEREIRA

Aos 13 de outubro de 2022, às 11:00h, na sala de audiência virtual do Anexo do Juizado Especial Criminal do Foro de Tupã, Comarca de Tupã, Estado de São Paulo, realizada neste formato conforme autorizado pelo E. Conselho Superior da Magistratura no Provimento CSM nº 2.651/2022 e pelos Comunicados CG nº 284/2020 e CG nº 208/2022, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). JOSÉ AUGUSTO FRANCA JÚNIOR, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais foi constatada e certificada a presença no sistema virtual do DD. Promotor(a) de Justiça MARCELO BRANDÃO FONTANA, do(a) Dr(a). Defensor EDE DONIZETI DA SILVA JÚNIOR e do réu. Pelas partes inicialmente foi dito que não viam impedimento à realização do ato pelo sistema virtual. Foi oportunizado à Defesa o direito de contato reservado com o réu através do sistema virtual. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dada a palavra ao(à) Defensor(a), que assim se manifestou: "MM. Juiz(a), a Defesa do réu provará sua inocência no transcorrer do processo". Na sequência, foi(ram) ouvida(s) 02 testemunha(s) do rol acusatório (PMS JOSÉ RENATO DOS SANTOS e MARCELO DE CARVALHO DUTRA) e o(a) réu(é) foi interrogado(a) sobre os termos da acusação, de acordo com o artigo 188, incisos I a VIII do CPP, mediante sistema de gravação de áudio e vídeo, na forma como autoriza o artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal. Fica consignado que a gravação desta audiência encontra-se disponível para consulta mediante acesso ao portal E-SAJ. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinada a realização dos debates, tendo sido dada a palavra ao(à) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, que se manifestou mediante gravação. Dada a palavra à Defesa, também se manifestou mediante gravação. Após, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença:

"Relatório dispensado nos termos do art. 81, §3º, da Lei Federal 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

WILLIAN DE MELO PEREIRA foi denunciado como incurso no art. 28 da Lei Federal 11.343/2006, pois, em 19 de julho de 2017, transportava para consumo próprio um cigarro de maconha, com pelo líquido de 0.98g e uma porção de maconha com peso líquido de 0.94g.

Após ampla instrução probatória, o Parquet reiterou o pleito condenatório em memoriais orais. A Defesa postulou a condenação a pena de advertência, Pois bem; a priori, verifico que o princípio da insignificância não se aplica ao presente caso. O porte para consumo de drogas ilícitas é proibido não apenas pelo mal que a substância faz ao usuário, mas também pelo perigo que o consumidor gera para a sociedade, ao estimular o narcotráfico e, conseqüentemente, diversos outros crimes. Por evidente, não se pode olvidar que a prática das condutas tipificadas pela legislação (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo) geram efetivo risco para a saúde da coletividade.

Com efeito, a caracterização do delito descrito no art. 28 da Lei de Drogas não está condicionada à ocorrência de lesão ao bem jurídico protegido. Bastaria a realização da conduta proibida para a presunção do perigo ao bem tutelado, como assim ocorreu. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, colocando em risco a saúde pública e seu ato torna-se um fator decisivo na difusão dos tóxicos. O objeto jurídico tutelado pela lei é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito.

Desta forma, reputo impossível afastar a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio com base no princípio da insignificância, ainda que ínfima a quantidade de droga apreendida, como se observa da jurisprudência pacífica da Corte Cidadã:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que ínfima a quantidade de drogas apreendidas. 2. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Vale dizer, o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 esgota-se, simplesmente, no fato de o agente trazer consigo, para uso próprio, qualquer substância entorpecente que possa causar dependência. Por isso mesmo, é irrelevante que a quantidade de drogas não produza, concretamente, danos ao bem jurídico tutelado, no caso, a saúde pública ou a do próprio indivíduo. 3. Em virtude da apreensão de pouco mais de 3 g de maconha em poder do ora agravante, o processo deve prosseguir em seu desfavor também em relação ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 387.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017).".

No tocante à inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, este Juízo posiciona-se de acordo com o entendimento pacífico do C. STJ quanto à conformidade do delito perante a Magna Carta, bem como a sua adequação a todo o arcabouço normativo, não havendo qualquer violação do princípio alteridade - uma vez que a circulação de substância entorpecente traz consigo elevada carga lesiva ao sustentar e aparelhar todo o sistema de consumo e tráfico de drogas existente na sociedade.

No mesmo sentir, "a punição, na hipótese, é de rigor para salva guardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a

indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (STF, RE 635660 SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, 22.3.2011).

Não obstante, nos termos das regras atinentes ao controle de constitucionalidade das leis, vige em nosso sistema a presunção da conformidade da norma à Magna Carta, até a manifestação definitiva do E. STF, no tocante à existência de constitucionalidade ou não. Desta forma, diante do entendimento deste Juízo pela constitucionalidade do preceptivo em apreço, é plenamente aplicável o artigo 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista a ocorrência da despenalização da conduta e não a sua descriminalização, permanecendo tal figura como fato típico penal. Confira-se o precedente a respeito:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. ARTIGO 16 DA LEI N. 6.368 /1976. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 11.343 /2006. DESCRIMINALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERA DESPENALIZAÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343 /2006. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso em ação cabível, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica. 2. Este Superior Tribunal, alinhando-se ao entendimento firmado pela Corte Suprema (Questão de Ordem no RE n. 430.105-9/RJ), também firmou a orientação no sentido de que, com o advento da Lei n. 11.343/2006, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização. 3. Uma vez constatada a existência de condenação definitiva anterior pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei n. 6.368 /1976, e considerando que a conduta disciplinada desse dispositivo legal (agora prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006) não deixou de ser crime, não há como se afastar da condenação do paciente a agravante genérica da reincidência, como pretendido. 4. Reconhecida a reincidência do paciente, mostra-se inviável a aplicação, em seu favor, da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006, haja vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício aos condenados reincidentes. 5. Habeas corpus não conhecido. STJ - HABEAS CORPUS HC 141541 MG 2009/0133514-0 (STJ), Data de publicação: 28/10/2013.".

Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, e encontram amparo no boletim de ocorrência (fls. 01/02); no auto de exibição/apreensão (fls. 05); na fotografia do estupefaciente (fls. 07), no laudo pericial toxicológico (fls. 08/10), o qual comprova a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, bem como pela prova oral produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório:

A testemunha JOSE RENATO DOS SANTOS, mencionou que no dia dos fatos fazia patrulhamento de rotina quando verificou um odor característico de entorpecentes que era oriundo de um veículo que trafegava pela via pública. Esclareceu que foi feita a abordagem ao acusado, sendo encontrado após busca pessoal e veicular, duas porções da substância conhecida como maconha. Mencionou que em entrevista, o acusado teria confessado a prática delitiva.

A testemunha MARCELO DE CARVALHO DUTRA, policial militar, mencionou que no dia dos fatos fazia o patrulhamento pela via pública quando se deparou com um veículo que trafegava pela via e apresentava odor forte e característico de entorpecentes. Asseverou que foi realizada a abordagem e após revista pessoal e veicular, encontraram duas porções de entorpecentes. Esclareceu que o acusado após breve entrevista confessou a prática delitiva.

O acusado WILLIAN DE MELO PEREIRA, ouvido em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Esclareceu que no dia dos fatos realmente portava os entorpecentes destinados ao seu consumo pessoal.

Compulsando os autos, atento à prova produzida, entendo que restou evidente a posse

dos entorpecentes por parte do acusado. Em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, considerando a quantidade de droga apreendida em posse do increpado (em seu ouvido), forçosa a conclusão de que o entorpecente apreendido, realmente, destinava-se a seu consumo pessoal.

Em que pese a negativa de Willian, colige-se dos autos que não há qualquer indício de que os agentes policiais tenham confabulado para acusar uma pessoa inocente. Assim, não vislumbro margem para o acolhimento do pleito absolutório por fragilidade das provas.

Portanto, considerando a natureza da droga (maconha), a quantidade apreendida (1.9g), o local da apreensão, as condições em que se desenvolveu a ação (vistoria dos agentes enquanto patrulhavam via pública), as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e aos antecedentes do agente (reincidente), indica o uso pessoal, demonstrando que a conduta de Willian enquadra-se perfeitamente àquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

Nada há que desabone as narrativas dos servidores públicos, que prestaram compromisso legal e ofereceram relato coeso e congruente. Em casos análogos: “esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha” - RHC 108586, Rel. Min Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, j. 09/08/2011.

Impende salientar ainda que as versões ofertadas pelos agentes penitenciários foram consonantes e complementares entre si, ao passo em que ambos informaram que durante inspeção de rotina, ao realizarem vistoria nos sentenciados que retornavam da frente de serviços tf E (Estação de Tratamento de Esgoto) na área externa do Semiaberto, apreenderam 01 (um) invólucro contendo substância com características do entorpecente maconha escondido dentro do ouvido do acusado.

Em casos análogos, decidiu o Egrégio Colegiado Bandeirante que “não se pode negar valor aos depoimentos de agentes penitenciários quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu” - Apelação 0003639-78.2014.8.26.0311, Rel. Des. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 13ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/04/2018; “Depoimento do agente penitenciário ouvido em juízo firme e sem desmentido - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras” - Apelação 0000983-05.2016.8.26.0530, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, 10ª Câmara de Direito Criminal, j. 19/10/2017; “Validade da prova oral consistente no depoimento do agente penitenciário. Autoria e materialidade devidamente comprovadas” - Apelação 0005796-32.2014.8.26.0082, Rel. Des. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 11/08/2016.

Diante desse panorama, vislumbro a existência de elementos de prova concretos no sentido de superar a presunção de inocência do acusado, sendo de rigor a prolação de um édito condenatório, nos termos adrede alinhavados. Destarte, convicto pela condenação do réu ao delito do art. 28 da Lei de Drogas a ele imputado, passo à dosimetria.

Considerando se trata de sentenciado que à época dos fatos não ostentava maus antecedentes, e era primário, reputo que é suficiente para fins de prevenção e reparação penais a aplicação de pena de advertência. Atento à reduzida nocividade do entorpecente bem como pelas circunstâncias judiciais do acusado, fixo a pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS NOCIVOS DAS DROGAS.

- Em arremate, atento ao disposto nos incisos do §2º do art. 315 do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019), cumpre destacar que os demais argumentos deduzidos pelas partes não são capazes, ao menos em tese, de infirmar a conclusão adotada por este Magistrado - uma vez que houve exaustiva análise de todas as proposições fáticas e jurídicas suscitadas pela acusação e defesa.

Conforme já decidido pelo Excelso Pretório quanto à fundamentação, certo que “não há divergência entre o que decidido pelo Tribunal a quo e o entendimento do Supremo Tribunal segundo o qual 'o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento' (AI 690.504-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 23.5.2008) (...)” - AI 742202 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª T., j. 06/04/2010.

Além disso, “(...) prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que 'o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte' (AgRg no AREsp n. 1.009.720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 5/5/2017) (...)” – excerto da ementa do AgRg no HC 466.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. do Superior Tribunal de Justiça, DJe 10/05/2019.

Também é digno de nota que o mesmo Sodalício, em exame do art. 489 do Código de Processo Civil (cuja redação é idêntica ao do preceptivo introduzido no Código de Processo Penal pelo projeto chamado de “Pacote Anticrime”), firmou o posicionamento que “(...) conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016) (...)” – excerto da ementa do REsp 1832993/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª T. STJ, DJe 13/12/2019.

Dispositivo

1) Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, e o faço para CONDENAR o acusado WILLIAN DE MELO PEREIRA como incurso no art. 28 da Lei Federal 11.343/2006, ao cumprimento da pena de ADVERTÊNCIA DOS EFEITOS NOCIVOS DAS DROGAS.

2) Oportunamente, verificando a renúncia expressa aos recursos manifestado pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, providenciando-se o necessário à execução da pena imposta acima, oficie-se ao IIRGD e TRE/SP, bem como COMUNIQUE-SE A DELEGACIA DE POLÍCIA DE ORIGEM PARA QUE DESTRUA AS DROGAS, EMBALAGENS, PETRECHOS E EVENTUAIS CONTRAPROVAS, nos moldes do art. 72 da Lei Federal 11.343/2006.

A advertência foi feita na própria audiência.

Portanto, cumprida a pena desde já, julgo extinta(s) a(s) punibilidade(s) de WILLIAN DE MELO PEREIRA, com qualificação(ões) nos autos, face ao cumprimento integral da pena (advertência), com fundamento no art. 66, inciso II, da Lei nº 7.210/84. Ausente interesse recursal do réu e do próprio Ministério Público, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado, procedendo-se às devidas anotações junto ao sistema e comunicações ao IIRGD e TRE.

Após, arquivem-se os autos.

Nada mais havendo, foi encerrada a audiência, lavrando-se este termo que depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Tendo sido a audiência realizada por videoconferência, ao final o presente termo foi exibido às partes, que concordaram com seus termos, ficando dispensada as assinaturas. Eu, Diego Vicentim Januário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006